

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR ALEXANDRE MANIR

FIGUEIREDO SARQUIS

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19-02-2025 – MUNICIPAL

JULGAMENTO

=====

Processo: TC-024666.989.24-9

Representante: José Eduardo Bello Visentin

Representada: Prefeitura Municipal de Limeira

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 196/2024, do tipo menor preço unitário, que tem por objeto o registro de preços para *“eventual aquisição de materiais esportivos”*.

Responsável: Mario Celso Botion (Prefeito à época).

Prefeito atual: Murilo Berbert Avigo Félix

Subscritor do edital: Luis Fernando Ferraz (Diretor de Gestão de Suprimentos).

Advogado cadastrado no e-TCESP: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP nº 168.357), Sidney Antonio da Costa (OAB/SP nº 94.445), Paulo Roberto Barcellos da Silva Junior (OAB/SP nº 224.028), Richard Paes Lyra Junior (OAB/SP nº 253.452), Yara Cristina Carpinini Amorim de Avila (OAB/SP nº 253.507), Aline Formaggio (OAB/SP nº 339.583) e Vanderley das Neves Silva (OAB/SP nº 354.309).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 69, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21. HABILITAÇÃO TÉCNICA. FALTA DE DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame de pedido de medida cautelar** no âmbito do do Pregão Eletrônico nº 196/2024, do tipo menor preço unitário, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**, que tem por objeto o registro de preços para *“eventual aquisição de materiais esportivos”*.

1.2 Insurgiu-se o **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial¹, em descompasso com o artigo 69 da Lei 14.133/21;
- b) imposição de atestado de capacidade técnica sem a eleição das parcelas de maior relevância²; e
- c) abusiva exigência de amostras³ para itens com pequena quantidade estimada, podendo a amostragem corresponder, em alguns casos, a 50% do objeto;

¹ 2.1.5. Não será admitida a participação de proponente:
(...)

2.1.5.2. Em recuperação judicial, exceto se a empresa estiver amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo licitatório
(...)

3.6. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.6.1. Nos termos das disposições do art. 69, da Lei nº 14.133/2021, para a habilitação econômico financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

(...)

3.6.1.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

² 3.4.1.1. Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

³ 1.5. DA DEMONSTRAÇÃO OU AMOSTRA DO OBJETO E VISTORIA TÉCNICA

DISPOSIÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E CRITÉRIOS DE ACETABILIDADE

a) Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 01 (uma) amostra dos itens ofertados, conforme especificações do ANEXO I, em até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da declaração de vencedor provisório, no endereço Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179, Centro, Limeira /SP, Secretaria Municipal de Administração, no Departamento de Gestão de Suprimentos, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega e cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

b) Todas as amostras deverão estar devidamente etiquetadas com o número do item, e nome da empresa. A falta de identificação prejudicará a análise e acarretará a desclassificação da licitante.

c) Será facultada a prorrogação do prazo estabelecido, desde que solicitada de forma fundamentada e antes do seu encerramento. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

d) Serão avaliados os padrões mínimos de aceitabilidade conforme especificações do ANEXO I.

e) Os resultados das avaliações serão divulgados por meio do site eletrônico www.limeira.sp.gov.br. Após a divulgação e homologação do resultado final do certame, as amostras da empresa vencedora ficarão retidas até a entrega definitiva do objeto desta licitação. As amostras reprovadas ou desclassificadas deverão ser recolhidas pelos fornecedores no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Limeira no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após o qual, não havendo a retirada, as mesmas poderão ser descartadas ou dada a devida destinação pela Administração, sem direito a ressarcimento.

1.3 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, requisitei, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame, previamente à realização do certame.

1.4 Notificada, a **Representada** defendeu a regularidade das cláusulas editalícias que dispõem sobre a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, entendendo estarem em conformidade com a Súmula nº 50 deste Tribunal.

Em relação à habilitação técnica, defendeu que a fixação de parcelas de maior relevância seria “inadequada em licitações cujo objeto não demanda habilidades específicas ou alta complexidade técnica. Para fornecimentos genéricos, como produtos industrializados ou materiais de consumo, a obrigatoriedade de atestados pode configurar uma restrição injustificada à competitividade”.

Por sua vez, argumentou que “as amostras aprovadas são retidas com o objetivo de compará-las às especificações dos materiais entregues, promovendo um controle de qualidade e assegurando que os itens fornecidos não tenham qualidade inferior à da amostra vencedora”.

Esclareceu, ainda, que, “concluída a entrega da totalidade do objeto da licitação, as referidas amostras ficam à disposição do fornecedor para a sua retirada, não permanecendo com o município”.

1.5 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pela parcial procedência da representação, afastando a crítica relacionada à ausência de parcelas de maior relevância, eis que “o critério de julgamento adotado foi o de ‘menor preço unitário’, de modo que a análise de atendimento aos requisitos de

f) Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), proceder-se-á conforme as regras de convocação estabelecidas neste edital.

g) Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e testados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

habilitação técnica recairá, por certo, sobre a comprovação de fornecimento anterior do item em disputa”.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 219-B, parágrafo único, do Regimento Interno, seja referendado o despacho por meio do qual foi concedida a cautelar pleiteada, para fins de imediata paralisação do certame.

3. VOTO

3.1 A Prefeitura Municipal de Limeira pretende o registro de preços para “*eventual aquisição de materiais esportivos*”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

3.2 De plano, embora reconheça que as disposições relacionadas à recuperação judicial e extrajudicial se encontram em sintonia com a Súmula nº 50, há de se ressaltar que aquele enunciado fora elaborado ainda na vigência da Lei nº 8.666/93, com o propósito de adequar a cláusula relacionada à concordata, extinta do ordenamento jurídico.

Todavia, a Nova Lei de Licitações, em seu artigo 69, de forma categórica, estabelece apenas a possibilidade de se requisitar “certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do

licitante”, hipótese que não abrange a recuperação judicial ou extrajudicial, como pretende a Representada.

Nesse sentido, aliás, vem decidindo este E. Plenário, a exemplo do voto proferido pelo e. Conselheiro MARCO AURELIO BERTAIOLLI, nos autos do TC-18450.989.24-9⁴:

“Procede, na esteira de entendimento jurisprudencial citado por ATJ-Jurídica⁵, censura à exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação, exegese do artigo 69, inciso II, da Lei 14.133/2021⁶.

Ao ensejo, propõe-se a este Egrégio Plenário reflexão sobre a possibilidade de emissão, à margem da decisão que vier a ser proferida, de Aviso aos jurisdicionados acerca da inaplicabilidade direta da Súmula TCESP nº 50⁷ após o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Tal como consta em menção expressa no edital divulgado pelo Município de Araraquara⁸, atuação rotineira deste Tribunal sobretudo em sede de exame prévio de edital tem demonstrado que muitos órgãos reproduzem a exigência de certidão de recuperação judicial com fundamento em aludido verbete que, se por muitos anos⁹ balizou

⁴ Sessão Plenária de 06-11-24.

⁵ Além do precedente citado por ATJ-Jurídica, o TC-022651.989.23-8, apreciado sob minha Relatoria em Sessão Plenária de 07/02/2024), pode-se elencar, dentre outros:

TC-023613.989.23, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 06 de março de 2024.

TC-001390.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 22 de maio de 2024.

TC-0013058.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini, sessão de 31 de julho de 2024.

TC-0098060.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 12 de junho de 2024.

TC-015854.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 04 de setembro de 2024.

TCs-019664.989.24, 019867.989.24 e 019874.989.24, Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 16 de outubro de 2024.

⁶ Lei 14.133/2021.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: (...)

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante

⁷ SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

⁸ EDITAL:

05. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

05.13.01. As empresas que estiverem em recuperação judicial deverão apresentar, na habilitação, o Plano de Recuperação homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

11.14.03. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.14.03.01. Certidão negativa de falência e no caso de empresas em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula 50 do TCE/SP.

⁹ Mais precisamente, desde 15 de dezembro de 2016, data de publicação da Resolução nº 10/2016.

legitimamente a atuação de nossos jurisdicionados, hoje não pode mais ser utilizado de maneira direta e integral dada a mudança legislativa.

Cabe registrar, a propósito do tema, que este Egrégio Plenário, sob Relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, assim deliberou em sessão de 14 de agosto último:

2.3 Ademais, encontra-se superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, o que impõe seja excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. (TC-014092.989.24).

Assim, no desempenho de sua missão institucional de orientar preventivamente para que os recursos públicos sejam adequadamente utilizados¹⁰ e com vistas a preservar a segurança jurídica, propõe-se, por ora, a emissão de ato orientativo por esta Corte, sem prejuízo do aprofundamento de estudos voltados a determinar o cancelamento da Súmula TCESP nº 50 não mais diretamente aplicável sob o figurino legislativo vigente”.

Portanto, à luz do atual contexto normativo, descabe a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, eis que o documento não é contemplado pela Lei nº 14.133/2021.

3.3 No que tange às amostras, há de se reconhecer que as disposições guardam consonância com o entendimento desta Corte, direcionando-se às licitantes mais bem classificadas, com prazo razoável para sua apresentação. Também necessário observar que serão os protótipos devolvidos às licitantes vencedoras, após concluída a execução do ajuste, o que se mostra em sintonia com sua finalidade, que é a de entregar itens com a mesma qualidade ao longo do contrato.

Nesse cenário, a despeito de, em alguns casos, a amostra corresponder a 50% do item licitado, como é o caso das redes de biribol e vôlei de piscina (2 unidades) e de beach tennis (2 unidades), não há como reputá-la desarrazoada, em face do disposto no artigo 41, inciso II, da NLL.

¹⁰ Conforme Planejamento Estratégico 2022-2026.

Ademais, a devolução das amostras às licitantes tende a ressarcir eventuais gastos que tenham inicialmente realizado.

De toda forma, entendo possível acolher o parecer do Órgão Ministerial para recomendar à Administração que “avalie a pertinência da manutenção de sua requisição para tais itens e/ou a possibilidade de substituição da exigência por catálogos e/ou fichas técnicas, evitando onerar demasiadamente as licitantes vencedoras e/ou desestimular a participação de potenciais interessados na disputa”.

3.4 Outrossim, insubsistente a crítica direcionada à habilitação técnica, porquanto, no presente certame, sendo o critério de julgamento adotado o de “menor preço unitário”, por óbvio que a demonstração de fornecimento recairá apenas sobre o item ou itens ofertados.

No entanto, como bem destacou o Órgão Ministerial, “a ausência de especificação de quantitativo/percentual mínimo a ser atendido pode resultar na exigência de comprovação da totalidade do objeto, a recomendar que a Administração aprimore o dispositivo questionado, observando os limites estabelecidos no art. 67, § 2º da Lei n.º 14.133/2021”.

3.5 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedente** a representação, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial; e
- b) definir o quantitativo/percentual mínimo a ser atendido para fins de habilitação técnica.

Recomendo, outrossim, como proposto pelo MPC, que avalie a pertinência da manutenção da exigência de amostras para itens com poucas

unidades e/ou a possibilidade de substituição da exigência por catálogos e/ou fichas técnicas.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR